

<제09장 무효등 확인소송.제07절 청구의 병합과 소의 변경>

[예상][9.07-1]무효확인청구와 취소청구의 병합 가능성 및 두 청구의 관계에 따른 판례의 입장

《【문제9.7】

<사례>

행정청 A는 甲에게 국제 체납을 이유로 `압류처분`을 내렸다. 甲은 해당 처분에 중대하고 명백한 하자가 있어 당연무효라고 생각하면서도, 혹시 법원에서 하자가 취소 사유에 불과하다고 판단할 경우를 대비하여 소송을 준비하고 있다. 이에 甲은 주위적으로는 압류처분의 무효확인을 구하고, 예비적으로는 압류처분의 취소를 구하는 소송을 한꺼번에 제기하려 한다. 한편, 乙은 행정청 B로부터 영업정지 처분을 받고 처분의 무효를 구하는 소송을 제기하여 심리 중인데, 소송 과정에서 하자가 무효에 이를 정도는 아니라는 점을 깨닫고 취소소송으로 소를 변경하고자 한다. 이때 乙이 소를 변경하려는 시점은 이미 취소소송의 제소기간이 도과한 상태이다.

(물음1) 甲이 제기하려는 `무효확인청구와 취소청구의 병합`이 허용되는지 여부와 관련하여, 두 청구의 관계(주위적·예비적 병합 vs 단순 병합)에 따른 판례의 입장을 기술하라.》

<문제9.7의 물음1> 무효확인청구와 취소청구의 병합 가능성 및 두 청구의 관계에 따른 판례의 입장

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 압류처분의 하자가 무효사유인지 취소사유인지 불확실한 상황에서 무효확인청구와 취소청구를 함께 제기하려 하는 상황이다. 쟁점으로 <무효확인청구와 취소청구의 병합 가능 여부와 관련하여 주위적·예비적 병합 및 단순 병합의 허용 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 무효확인청구와 취소청구의 관계에 따른 병합 형태별 허용 여부를 기술한다.

II. 행정소송상 관련 청구의 병합

1. 병합의 의의 및 근거

- 병합이란 하나의 소송절차에서 여러 개의 청구를 동시에 제기하거나 기존 소송에 다른 청구를 추가하는 것을 말한다. “행정소송법 제10조”는 소송의 효율성을 높이고 관련 분쟁을 일회적으로 해결하기 위해 관련 청구소송의 병합을 허용하고 있다.

2. 병합의 형태

(1) 단순 병합

- 여러 개의 청구를 병렬적으로 제기하여 법원이 모두에 대하여 심판을 하도록 하는 형태이다. 청구 상호 간에 양립이 가능한 경우에 주로 활용된다.

(2) 선택적 병합

- 여러 개의 청구 중 어느 하나가 인용되면 다른 청구에 대해서는 심판할 필요가 없는 형태이다. 청구 상호 간에 양립할 수 없는 관계에 있을 때 사용된다.

(3) 주위적·예비적 병합

- 주위적 청구가 기각될 것을 대비하여 예비적 청구를 제기하는 형태이다. 법원은 주위적 청구가 이유 없을 때에만 비로소 예비적 청구를 심리한다.

III. 무효확인청구와 취소청구의 병합에 관한 판례의 입장

1. 주위적·예비적 병합의 허용 여부

(1) 판례의 태도

- “대법원”은 동일한 행정처분에 대하여 무효확인청구와 취소청구를 주위적·예비적 병합의 형태로 제기하는 것을 명시적으로 허용하고 있다. “판례”는 무효확인소송과 취소소송은 소송물인 처분의 위법성이라는 기초는 동일하지만, 하자의 정도에 따라 양립할 수 없는 관계에 있다고 본다.

(2) 심리 방식

- 법원은 주위적 청구인 무효확인청구를 먼저 심리하여 그 하자가 중대하고 명백하여 무효라고 인정되면 예비적 청구인 취소청구에 대해서는 판단하지 않는다. 만약 하자가 존재하지만 무효 사유에는 이르지 않는 취소 사유에 불과하다고 판단될 때 비로소 예비적 청구를 심리하여 처분을 취소하게 된다.

2. 단순 병합의 허용 여부

(1) 판례의 태도

- “대법원”은 동일한 행정처분에 대하여 무효확인청구와 취소청구를 단순 병합의 형태로 제기하는 것은 허용되지 않는다고 판시한다. “판례”는 양청구가 동일한 행정처분을 대상으로 하는 경우, 그 하자가 무효 사유이거나 취소 사유인 것 중 하나일 수밖에 없으므로 양립 불가능한 관계라고 판단하기 때문이다.

(2) 부적법 판정의 근거

- 만약 단순 병합으로 제기되었다 하더라도 법원은 이를 주위적·예비적 병합으로 보아 심리하거나, 병합의 형태를 명확히 하도록 설명권을 행사해야 한다. 무효와 취소를 동시에 선택적으로 청구하는 것은 청구의 취지가 모순되어 허용되지 않는다는 것이 “판례”의 일관된 입장이다.

IV. 사안의 적용

1. 甲의 병합 신청의 적법성

- 사안의 甲은 주위적으로 무효확인을, 예비적으로 취소를 구하는 소송을 제기하려 한다. 이는 “판례”가 허용하는 전형적인 주위적·예비적 병합의 형태이다. 따라서 甲의 소 제기는 적법한 병합으로 인정될 수 있다.

2. 법원의 심리 방향

- 법원은 우선 압류처분의 하자가 중대하고 명백한지 심리한다. 만약 하자가 중대·명백하여 당연무효라면 무효확인판결을 내리고 소송을 종료한다. 그러나 하자가 중대·명백하지는 않으나 위법함이 인정된다면 예비적 청구인 취소소송의 요건(제소기간 등)을 검토한 후 취소판결을 내리게 된다.

V. 결론

- 동일한 처분에 대하여 무효확인을 구하는 청구와 취소를 구하는 청구는 성질상 양립할 수 없는 관계에 있다. “대법원”은 이러한 관계를 고려하여 두 청구의 단순 병합이나 선택적 병합은 허용하지 않으나, 주위적·예비적 병합의 형태는 국민의 권리구제 범위를 넓히기 위해 적법한 것으로 인정하고 있

다. 이러한 법리는 원고가 하자의 정도를 정확히 판단하기 어려운 실무적 상황을 배려하여 소송 경제와 실효적 권리구제를 동시에 달성하려는 행정쟁송 법상의 배려를 반영하고 있다.